

1500951-65.2021.8.26.0621

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniel Otero Pereira da Costa

Comarca: Lorena

Foro: Foro de Lorena

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/06/2022

... atestado pelo expert serem, de fato, oriundas do tráfico de drogas, tudo a demonstrar sem envolvimento perene com o tráfico de drogas.

Neste sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. (...). 1. Na hipótese dos autos, a causa especial de redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.

11.343/06 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lorena

Foro de Lorena - Vara Criminal

Av. Eptácio Santiago, 99, Lorena-SP - cep 12600-530

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500951-65.2021.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500951-65.2021.8.26.0621

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2297863/2021 - 2º Distrito Policial de Lorena, 21151393 -

2º Distrito Policial de Lorena, 1022/21/204 - 2º Distrito Policial de Lorena,

2297863 - DEL.POL.LORENA, 2297863 - 02º D.P. LORENA, 1022/21/204 - 02º D.P. LORENA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ENZO FERNANDES INACIO

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. Daniel Otero Pereira da Costa

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de ENZO FERNANDES INÁCIO, qualificado nos autos, pela prática dos delitos previstos nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06, e 12, da Lei 10.826/03, em concurso material, conforme os fatos narrados na peça inicial de fls. 119/121.

Recebida a denúncia em 10/12/2021 (fls. 126/127), o réu foi citado, apresentando a sua resposta à acusação às fls. 131/132. Não sendo caso de absolvição sumária, designou-se audiência de instrução e julgamento, nos termos dos artigos 397 e seguintes, do Código de Processo Penal (fls. 133/136).

No curso da instrução foram ouvidas as testemunhas e o réu interrogado, ao final. Na sequência, as partes apresentaram alegações finais em audiência (mídia às fls. 186).

O Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal, com a condenação do acusado, nos termos da denúncia.

A defesa, por sua vez, requereu a absolvição do acusado, preliminarmente, sustentando a nulidade das provas, por invasão de domicílio pelos policiais militares. Subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta tipificada no artigo 12, da Lei 10.826/03, para a causa de aumento do artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343/06, aplicando-se o princípio da consunção. Pleiteou, ainda, o reconhecimento das atenuantes relativas à menoridade relativa, e confissão, além da aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, malgrado respeito destinado à nobre defensora, não é o caso de acolhimento da preliminar invocada.

De fato, este Juízo não desconhece o entendimento que vem se formando no Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de prévia autorização do morador da residência para incursão policial, em respeito ao direito à inviolabilidade domiciliar.

Porém, entendo que a ação policial no caso em tela observou os limites da Constituição Federal.

Com efeito, diferentemente do que ocorre em outras situações, na hipótese dos autos, a entrada dos policiais militares no imóvel foi precedida pelo comportamento do réu, que arremessou um objeto e tentou fugir correndo para dentro do imóvel, sendo prontamente seguido pelos agentes da lei, como se verá à frente nas provas orais.

Anoto que as fotografias de fls. 65/68 não retiram a credibilidade das palavras dos agentes públicos, vez que desacompanhadas de elementos mínimos a indicar que estes foram os responsáveis por provocar o estrago nelas demonstrado. Aliás, o que se vê facilmente é a ausência da parte interna da fechadura (fl. 65), e a chapa contra testa (fl. 67).

Logo, em virtude do estado flagrancial, expressamente excepcionada pela própria norma constitucional que garante a inviolabilidade domiciliar (artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal), mostrou-se perfeitamente legítimo o agir dos agentes públicos na espécie.

Insta salientar que o próprio Supremo Tribunal Federal se debruçou sobre o assunto, em sede de repercussão geral (Tema 280), e estabeleceu as diretrizes para o controle judicial nessas hipóteses, firmando a seguinte tese:

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.

Portanto, não se pode dizer que a conduta dos agentes públicos não estava protegida em fundadas razões (justa causa), à luz daquela postura do próprio réu.

A propósito, em caso muito semelhante ao destes autos:

“TRÁFICO DE DROGAS – Preliminar de nulidade do feito, sob a alegação de invasão de domicílio - Apelação buscando a absolvição ou desclassificação para o delito de uso de drogas ou reconhecimento de tráfico privilegiado e alegação de inconstitucionalidade da pena de multa – IMPOSSIBILIDADE – Preliminar afastada – Motivação para busca domiciliar se deu em razão da reação do apelante que tentou fugir – Ação policial dentro da legalidade, não se configurando violação de domicílio - Prova produzida suficiente para embasar o decreto condenatório para o tráfico de drogas - Apreensão de 15 porções de cocaína (15,92 gramas) e 15 porções de "crack" (12,58 gramas)- Ausência de elementos que indiquem que as drogas apreendidas fossem para uso próprio - Incabível a desclassificação – (...) – RECURSO NÃO PROVIDO”. (TJSP; Apelação Criminal 1500202-49.2019.8.26.0126; Relator (a): Ruy Alberto Leme Cavalheiro; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Caraguatatuba - Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/06/2020; Data de Registro: 16/06/2020) (Sublinhado meu).

No mérito, a ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva encontra-se cabalmente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 03/07), auto de exibição e apreensão (fls. 08/09), fotografias (fls. 32/40), laudo de constatação provisória (fls. 24/27) e laudo químico toxicológico definitivo (fls. 169/171 e 172/177), cujos resultados foram positivos para “cocaína e tetrahidrocannabinol – THC – maconha”, substâncias presentes nas listas, da Portaria SVS/MS 344/98, e atualizações posteriores; laudos periciais da arma de fogo e das munições (fls. 178/181 e 182/184), cujos resultados atestaram o potencial lesivo das munições e a eficácia do armamento; bem como as provas orais existentes nos autos.

Com relação à autoria, esta restou igualmente confirmada. A começar pela confissão de Enzo.

Decerto, durante o ato destinado à sua autodefesa, o réu admitiu que guardava as drogas para terceiro, por estar passando dificuldades financeiras à época em virtude do nascimento de seu filho. Afirmou que recebeu os entorpecentes no mesmo dia do ocorrido, e que receberia pela tarefa, R\$ 500,00 (quinhentos reais). Aduziu que os agentes da lei invadiram o seu apartamento enquanto dormia. Com relação à arma de fogo, disse que já a possuía para sua própria proteção. Por fim, disse que não conhecia os policiais militares que o prenderam.

No entanto, esclareço que a prova acusatória não se resume à confissão do acusado.

Com efeito, o policial militar Clemilson Rodrigues de Souza confirmou a narrativa descrita na denúncia. Contou que quando se aproximava do imóvel, observou o réu, que ao vê-lo, dispensou um saco plástico contendo as drogas apreendidas, correndo para o interior do prédio. Ato contínuo, saiu ao encalço de Enzo, conseguindo abordá-lo quando este entrava em um imóvel. Antes, porém, o réu arremessou uma arma de fogo. Esclareceu que o apartamento não parecia ser habitado porém, informações davam conta de que o local era utilizado por traficantes. Ao final, o policial confirmou que a porta do apartamento estava aberta quando ingressou naquele local.

Seu companheiro de farda Italo Odorisi Moreira fez coro às suas palavras, acrescentando que o réu já era conhecido em razão de seu longo e extenso histórico infracional.

Essa, portanto, a prova oral.

Pois bem. Como se vê, a prova em juízo não destoou em momento algum da confissão do réu, encontrando amparo no conjunto probatório, em especial, nos depoimentos dos

policiais responsáveis por realizarem sua prisão em flagrante.

De fato, a confissão judicial isenta de vícios e coações, como a trazida pelo increpado aos autos, fornece elemento seguríssimo de prova, que por si só serve de lastro a condenação.

Se, por outros elementos de convicção, a palavra do réu soasse inverídica ou estivesse isolada nos autos, o desfecho condenatório poderia ser contestado, o que não aconteceu no presente caso, posto que a confissão está no mesmo sentido das palavras das testemunhas, confirmando a versão acusatória da exordial.

Na verdade, o único ponto em que a prova oral não está em harmonia com a confissão do acusado é sobre o momento em que este teria encontrado os policiais.

Aqueles que acompanham de perto as decisões deste Magistrado, bem sabem a credibilidade que costume conferir às palavras dos policiais, sejam eles, militares, civis, federais, rodoviários federais, ou mesmo qualquer outro agente de segurança pública, seguindo, aliás, a maioria da jurisprudência dos nossos tribunais.

Confira-se o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça - STJ e do Tribunal de Justiça deste estado - TJSP:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016). 3. Agravo regimental não provido". (STJ; AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC; Relator: Ministro Ribeiro Dantas; Órgão Julgador: Quinta Turma; Data do Julgamento: 05/03/2020; Data da publicação: 23/03/2020); e

"Apelação criminal. Tráfico de entorpecente. Materialidade delitiva demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão da substância entorpecente, laudo de exame químico-toxicológico e prova oral. Autoria comprovada pela palavra de testemunhas policiais - Depoimentos insuspeitos e harmônicos, suficientes para alicerçar o decreto condenatório - Decisão de primeiro grau ratificada por seus próprios fundamentos - (...) Recurso desprovido". (TJSP; Apelação Criminal 1514240-51.2019.8.26.0228; Relator: José Raul Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 22ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/04/2020; Data de Registro: 30/04/2020) (Ênfase na reprodução).

E assim o faço, não só pela presunção de legitimidade que a própria lei confere aos atos por eles praticados, em razão da natureza pública da função que exercem, mas, também, por conta do total desinteresse deles em incriminar inocentes.

Afinal, como acreditar que policiais militares; cuja função precípua é impedir que a legislação penal seja inobservada nas ruas, ou nas estradas federais, caso, também, da polícia militar e da rodoviária federal, respectivamente, ou mesmo, investigar a autoria daqueles que a violaram, como é o caso da polícia civil e federal; vá, eles próprios, violá-la, com o fito de incriminarem um inocente? Não faz qualquer sentido!

E não é só! Há, ainda, mais uma razão para se atribuir grande importância à palavra de tais agentes públicos: na maior parte das vezes, eles são os únicos dispostos a testemunharem sobre o que realmente viram sobre determinado crime.

Por motivos óbvios, ressalvado as pessoas ligadas ao criminoso por vínculo de parentesco, afinidade, ou mesmo amizade, poucas são as pessoas que se dispõem a testemunhar, seja em sede policial, ou mesmo em Juízo, a respeito de um determinado crime. E, infelizmente, é forçoso admitir que assim o fazem por um motivo justificável, ou, ao menos, compreensível: medo de represálias.

Decerto, conhecendo-se a triste realidade da violência urbana existente em um país pobre igual ao nosso, não é difícil imaginar o receio de um morador da periferia, onde também reside a maior parte dos traficantes e, por via de consequente, são instalados os pontos de venda de drogas nas cidades, se apresentar em sede policial e, depois, em Juízo, contar o que seu vizinho traficante faz em sua rua, por exemplo.

Nesta toada, negar a validade do testemunho de tais agentes de segurança implicaria negar vigência às leis penais. Na prática, estas restariam ineficazes.

Isso não significa, lado outro, de modo algum, que as palavras dos policiais e agentes públicos em geral tenham peso superior às demais. Pode-se dizer que, em se tratando de provas, não existe hierarquia entre elas, todas são relativas.

É a essência do sistema da persuasão racional, disposto no artigo 155, "caput", do Código de Processo Penal, adotado atualmente:

"O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas".

Outro não é o entendimento do nosso Tribunal de Justiça:

"Embargos de Declaração. Oposição contra acórdão. Prequestionamento. Violação ao artigo 156 do CPP em face do que dispõe o artigo 203 do mesmo código. Inocorrência. Alegação de que não constou no decisum o critério de avaliação da credibilidade dos depoimentos de testemunhas que teriam se retratado em juízo. Omissão não configurada. Valoração da prova de acordo com seu conteúdo, coerência e harmonização com os demais elementos constantes dos autos. Sistema da persuasão racional ou do livre convencimento motivado (art. 155 do CPP). Liberdade do juízo na ponderação das provas produzidas. Consideração dos elementos de convicção que se mostraram mais confiáveis e aptos a revelar a verdade dos fatos. Julgamento plenamente justificado. Embargos rejeitados". (TJSP; Embargos de Declaração Criminal 0005867-59.2002.8.26.0242; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Igarapava - Vara Única; Data do Julgamento: 10/11/2009; Data de Registro: 03/12/2009) (Sublinhado meu).

Fixada tal diretriz, observo que o caso, ora em apreço é mais um dentre tantos outros no qual o réu tenta, em vão, desacreditar a fala dos agentes da lei, sem produzir sequer um início de prova da sua alegação.

Contudo, a demonstrar a confiabilidade da palavra dos policiais militares envolvidos no caso, ora em julgamento, em detrimento do enredo trazido em juízo por Enzo, aponto o fato daqueles terem mantido narrativa uniforme ao longo de toda perseguição criminal, ao contrário daquele que perante à autoridade policial, confessou apenas o porte da arma de fogo, negando o tráfico.

Saliente-se que em seu interrogatório policial o réu fazia-se acompanhar por

defensora (fls. 18/19).

Além disso, o acusado não apresentou nenhuma prova de que a dinâmica fática tenha se desenrolado de modo diverso daquela apontada pelos policiais militares, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe recaía neste tocante, a teor do disposto no artigo 156, caput, do Código de Processo Penal.

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO (MACONHA, COCAÍNA E CRACK) – OBJETIVA A ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DA PENA, ABRANDAMENTO DO REGIME E DETRAÇÃO PENAL – IMPOSSÍVEL ATENDER AOS PLEITOS – PRISÃO EM FLAGRANTE EM PONTO DE VENDA E NA POSSE DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS – NEGATIVA DO RÉU ISOLADA E ACUSAÇÃO DE EXTORSÃO RECHAÇADAS PELAS DEMAIS PROVAS, EM ESPECIAL DIANTE DOS DEPOIMENTOS SEGUROS E HARMÔNICOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE – O ÔNUS DA PROVA QUANTO AO ÁLIBI É DO RÉU, NOS TERMOS DO ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – A PENA FOI FIXADA COM CRITÉRIO, FUNDAMENTADOS TODOS OS ACRÉSCIMOS – A QUANTIDADE DE PENA E A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA JUSTIFICAM O REGIME FECHADO – RECURSO DESPROVIDO”. (TJSP; Apelação Criminal 0001394-33.2016.8.26.0535; Relator (a): Euvaldo Chaib; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarulhos - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/04/2020; Data de Registro: 16/04/2020) (Ênfase na reprodução).

No mais, insta salientar ser desnecessário para configuração do crime de tráfico de drogas que o agente seja flagrado em atos efetivos de mercancia, bastando apenas a prática de uma das múltiplas ações proibidas pelo tipo penal em questão, devendo a finalidade mercantil ser demonstrada pelas circunstâncias do caso, como nos presentes autos, conforme acima fundamentado.

Outro não é o entendimento da jurisprudência:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Recurso defensivo – Autoria e materialidade delitivas comprovadas – Prisão em flagrante e firmes depoimentos dos policiais militares – Desclassificação da conduta para a prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06 – Descabimento – Tipo penal que prevê diversas condutas – Desnecessidade da prova da efetiva mercancia – Condenação mantida – (...) Recurso não provido”. (TJSP; Apelação Criminal 1500932-98.2019.8.26.0566; Relator: Roberto Porto; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 10/12/2019; Data de Registro: 12/12/2019) (Ênfase na reprodução).

Importante registrar, outrossim, que dificuldades financeiras não configuram a excludente de ilicitude prevista no artigo 23, do Código Penal.

Isto porque não se insere no conceito de estado de necessidade a prática do tráfico de entorpecentes, como asseverado por esse increpado em sua autodefesa, já que somente configura o estado de necessidade, casos envolvendo involuntariedade e estado atual, o que não ocorre neste caso, na medida em que pendências financeiras contraem-se por livre e espontânea vontade. Além disso, sempre existem outras formas de quitá-las com o passar do tempo.

Neste sentido, o mesmo entendimento recente do nosso Tribunal em caso muito semelhante:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO – (...) – ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DA PENA E SUBSTITUIÇÃO POR ALTERNATIVAS – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM CONTRADITÓRIO – DIFICULDADES FINANCEIRAS NÃO JUSTIFICAM A ESCOLHA DO TRÁFICO COMO FONTE DE RENDA – CONDENAÇÃO DE RIGOR – (...) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO”. (TJSP; Apelação Criminal 1500200-93.2020.8.26.0498; Relator (a): Euvaldo Chaib; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão

Bonito - Vara Única; Data do Julgamento: 31/03/2022; Data de Registro: 31/03/2022).

Lado outro, com relação à conduta do artigo 12, da Lei 10.826/03, razão assiste à defesa.

Diante da sucessão de condutas criminosas, como a de trazer consigo e guardar, para fins de tráfico, entorpecentes, tipificadas no artigo 33, da Lei 11.343/06, e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, do artigo 12, da Lei 10.826/03, importante destacar que o porte do armamento por Enzo deu-se no mesmo contexto fático da guarda de drogas, o que configura o chamado trata-se de "tráfico armado", em que a presença do armamento tem a finalidade de garantir a segurança da vil empreitada.

Logo, tendo em vista que o crime-meio é absorvido pelo delito-fim, de acordo com o princípio da consunção, embora não capitulado na denúncia dessa forma, é lícito ao julgador, nos moldes do artigo 383, do Código de Processo Penal, dar aos fatos descritos na peça vestibular acusatória definição jurídica diversa da que consta, ainda que, em consequência, tenha que aplicar pena mais, ou menos, grave.

Isso ocorre porque o réu não se defende da capitulação atribuída, mas sim, dos próprios fatos descritos na denúncia. É a chamada emendatio libelli, a qual permite a este Magistrado proceder à correção da inicial, resultando tão somente no necessário ajuste dos fatos narrados à correta tipificação.

Ressalte-se que tal procedimento não acarreta qualquer surpresa à defesa, que assim pleiteou em suas alegações finais, e à acusação, que descreveu essa conduta na denúncia, razão pela qual mostra-se desnecessária a intervenção anterior a este ajuste das partes.

Assim, ainda que da exordial acusatória não tenha constado a causa de aumento do artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343/06, vê-se a correta descrição da conduta censurada.

A propósito, em recente julgado:

"(...) Tráfico de Drogas - (...) Estatuto do Desarmamento - Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido- Afastamento por força do princípio da consunção - Crime-fim que absorve o crime-meio - Laudo pericial a atestar a eficácia da arma de fogo ao disparo (...)". (TJSP; Apelação Criminal 1502218-67.2020.8.26.0537; Relator (a): Cesar Augusto Andrade de Castro ; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Bernardo do Campo - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/03/2022; Data de Registro: 22/03/2022) (Sublinhado meu).

Por fim, esclareça-se que o laudo pericial realizado na arma de fogo e nas munições atestou o potencial lesivo desses armamentos (fls. 178/181 e 182/184).

Destarte, diante da robustez da prova acusatória, o caso é de condenação, por violação ao tipo penal descrito no artigo 33, da Lei 11.343/06, combinado com o artigo 40, inciso IV, da mesma lei.

Passo à calibragem penal.

Nos termos do artigo 42, da Lei de Drogas, o juiz na aplicação da pena deve considerar, com preponderância às circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, a natureza, quantidade, personalidade e conduta social.

Ainda que o réu seja primário e sem antecedentes criminais; certo é que a quantidade e diversidade dos narcóticos apreendidos (733,93 gramas, peso líquido, de "cocaína", distribuídos em 1.090 pinos plásticos, do tipo eppendorf; 74,82 gramas, peso líquido, de "cocaína", distribuídos em 365 pinos plásticos, do tipo

eppendorf ; 974,06 gramas, peso líquido, de "maconha", no formato de um "tijolo"; 76,61 gramas, peso líquido, de "cocaína", distribuídos em 104 pinos plásticos, do tipo eppendorf; e 373,39 gramas, peso líquido, de "cocaína", à granel), indicam risco desmedido sofrido pelo bem jurídico tutelado pelo tipo penal em questão, por conta da conduta censurada. Afinal, trata-se de mais de dois quilos de "cocaína" e praticamente um quilo de "maconha".

Logo, tenho por bem fixar a pena-base elevada em 1/3 (um terço) do piso legal, ou seja, em 06 anos e 08 meses de reclusão e ao pagamento de 666 dias-multa.

Na segunda fase, em razão da confissão espontânea, forte no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, reduzo a pena em 1/6 (um terço), ao patamar de 05 anos, 06 meses e 20 dias, e 555 dias-multa. Não obstante o requerimento defensivo, não incide à espécie a atenuante da menoridade relativa, vez que o réu já havia completado vinte e um anos à época dos fatos (nascido em 19/03/2000 - fls. 03).

Confira-se:

"APELAÇÃO CRIMINAL - (...) RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA - NÃO VERIFICADO - Acusado contava com 21 anos completos à época dos fatos. (...)". (TJSP; Apelação Criminal 1505687-70.2020.8.26.0554; Relator (a): Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santo André - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/11/2021; Data de Registro: 10/11/2021). Não existem agravantes

Na terceira e última fase, tal como fundamentado acima, incide a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343/06, aplicando-se um percentual na ordem de 1/5 (um quinto), já que a arma portada pelo acusado encontrava-se municiada, e em via pública, conforme os elementos probatórios dos autos. Assim, estabeleço, em definitivo, a pena em 06 (seis) anos e 08 (oito) anos de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, à míngua de outras causas alteradoras.

Inaplicável o redutor previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, pois as circunstâncias do caso concreto revelam a profunda intimidade de Enzo com o narcotráfico, não obstante primário aos olhos da lei penal.

Com efeito, além da vultuosa quantidade de narcóticos e os demais a petrechos apreendidos em seu poder, dificilmente confiada à neófito no mundo criminoso, o réu não comprovou ofício lícito, muito pelo contrário, disse que fazia do tráfico a sua fonte de renda, pois os "bicos" haviam cessados.

Em reforço a tal conclusão, cito a apreensão de arma de fogo, utilizada para a intimidação difusa e coletiva, com o fim de garantir o sucesso da vil atividade, assim, como de caderno com possíveis anotações sugestivas da contabilidade do vil comércio que, devido às expressões utilizadas, em códigos e caligrafia sofrível não foi atestado pelo expert serem, de fato, oriundas do tráfico de drogas, tudo a demonstrar sem envolvimento perene com o tráfico de drogas.

Neste sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. (...). 1. Na hipótese dos autos, a causa especial de redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 foi afastada não somente pela quantidade de drogas apreendidas - 17kg de maconha -, mas, também, em virtude da existência de outros elementos fáticos, notadamente a apreensão de balança de precisão e outros apetrechos para a prática da traficância. (...) 2. A quantidade e a natureza da droga demonstram a gravidade concreta do delito, justificando, por força do princípio da individualização da pena, o agravamento do aspecto qualitativo (regime) da pena. 3. Agravo regimental

desprovido. (AgRg no HC 707.818/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022) (Sublinhei).

Mas não é só: outro fato a demonstrar que o réu vem se dedicando às atividades criminosas é que, durante a sua menoridade, ou seja, há pouco tempo (o réu completou 21 anos meses antes dos fatos ora sub judice), ele também foi processado cinco vezes e cumpriu três medidas socioeducativas por atos infracionais equiparados ao tráfico de drogas, furto e roubo, conforme certidão de fls. 52/53.

Confira-se o mesmo entendimento do nosso E. Tribunal de Justiça, em recentes julgados:

“TRÁFICO DE ENTORPECENTES - (...) - Condenação mantida. PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO - (...) - Inviável o redutor do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Apelante preso em flagrante menos de um mês após completar a maioridade penal e que respondeu a inúmeros procedimentos de apuração de ato infracional - (...)”. (TJSP; Apelação Criminal 1500188-53.2021.8.26.0172; Relator (a): Gilberto Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Eldorado Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 31/05/2022; Data de Registro: 31/05/2022); e

“Tráfico de entorpecentes - Prisão em flagrante - Confissão judicial - Depoimento de policiais seguros, coerentes e sem desmentidos - Responsabilidade do acusado comprovada - Condenação mantida; Tráfico de entorpecentes - Redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 - Réu que, embora primário, esteve envolvido em diversos atos infracionais - Indicação de que faz do crime seu meio de vida - Benefício incabível - Precedentes - (...)”. (TJSP; Apelação Criminal 1500955-14.2021.8.26.0618; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Pindamonhangaba - Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/05/2022; Data de Registro: 31/05/2022) (Ênfase nas reproduções).

Assim, veja-se que todos esses elementos, indicam claramente que o indigitado é pessoa que vem trilhando o caminho do crime, dedicando-se às atividades criminosas, situação que afasta a incidência dessa causa de diminuição de pena, visto que não existe prova direta dessa circunstância, “os criminosos não circulam com uma 'carteira de identificação de pessoa dedicada a atividades criminosas'”, como bem lançado pelo Ministro Luiz Fux, do C. Supremo Tribunal Federal, em julgado que assim se encontra a ementa:

“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRESUNÇÃO HOMINIS. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS. APTIDÃO PARA LASTREAR DECRETO CONDENATÓRIO. SISTEMA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...) ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENHIDA. CIRCUNSTÂNCIA APTA A AFASTAR A MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06, ANTE A DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ORDEM DENEGADA. 1. O princípio processual penal do favor rei não ilide a possibilidade de utilização de presunções hominis ou facti, pelo juiz, para decidir sobre a procedência do ius puniendi, máxime porque o Código de Processo Penal prevê expressamente a prova indiciária, definindo-a no art. 239 como “a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias”. Doutrina (LEONE, Giovanni. Trattato di Diritto Processuale Penale. v. II. Napoli: Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene, 1961. p. 161-162). Precedente (HC 96062, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 06/10/2009, DJe-213 DIVULG 12-11-2009 PUBLIC 13-11-2009 EMENT VOL-02382-02 PP-00336). 2. O julgador pode, através de um fato devidamente provado que não constitui elemento do tipo penal, mediante raciocínio engendrado com supedâneo nas suas experiências empíricas, concluir pela ocorrência de circunstância relevante para a qualificação penal da conduta. 3. A criminalidade dedicada ao tráfico de drogas organiza-se em sistema altamente complexo, motivo pelo qual a exigência de prova direta da dedicação a esse tipo de atividade, além de violar o sistema do livre convencimento motivado previsto no art. 155 do CPP e no art. 93, IX, da Carta Magna, praticamente impossibilita a

efetividade da repressão a essa espécie delitativa. 4. (...) 5. In casu: (i) consta dos autos que o paciente, em concurso com um adolescente, transportava e tinha em depósito, para consumo de terceiros, 6,280 Kg (seis quilos e duzentos e oitenta gramas) de maconha, e 787,9 gramas de cocaína em pedra, acondicionadas em invólucros, disso resultando sua condenação a 5 (cinco) anos de reclusão e a 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado, por estar incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006; (ii) para fundamentar a inaplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, o Juízo de origem ponderou negativamente as circunstâncias do crime, destacando a forma como a droga estava acondicionada e o concurso de pessoas, com envolvimento de adolescente, de forma a facilitar a comercialização, tudo conduzindo à conclusão de que não se trata de uma ação individual e ocasional, mas sim que o paciente se dedicava a atividades criminosas; (iii) apesar da robusta fundamentação, sustenta o impetrante que não houve adequada motivação do arredamento da aludida minorante, pois entende que teria sido considerada apenas a quantidade da droga. 6. O juízo de origem procedeu a atividade intelectual irrepreensível, porquanto a apreensão de grande quantidade de droga é fato que permite concluir, mediante raciocínio dedutivo, pela dedicação do agente a atividades delitivas, sendo certo que, além disso, outras circunstâncias motivaram o afastamento da minorante. 7. Ordem denegada". (STF; HC 101.519/SP; Relator: Min. Luiz Fux; Órgão Julgador: 1ª Turma; Data do julgamento: 20/03/2012; Data da publicação: 26/04/2012).

Assim, como determina a lei, tal redutora não se destina àquele que faz do tráfico de drogas o seu meio de vida, mas sim, ao agente que age por um impulso esporádico, em caso isolado, incidindo, portanto, em situações específicas e excepcionais, quando evidenciado que o pequeno tráfico se tratou de singelo desvio na vida do acusado, não sendo a hipótese destes autos.

Registro, por fim, que tal entendimento encontra-se em linha, ainda, com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, já que a quantidade de droga apreendida não foi o único elemento a ensejar a não aplicação do § 4º, do artigo em assunto, não se podendo cogitar em bis in idem.

Nesse sentido:

"PENAL, PROCESSO PENAL E CONSTITUCIONAL. DOSIMETRIA DE PENA. PECULIARIDADES DO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE A SER OBSERVADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO OU MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO TOLERÂNCIA NA ORDEM CONSTITUCIONAL. RECURSO PROVIDO PARA RESTAURAÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. 1. A dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador. 2. Em regra, abre-se espaço, em sua primeira fase, à atuação da discricionariedade ampla do julgador para identificação dos mais variados aspectos que cercam a prática delituosa; os elementos negativos devem ser identificados e calibrados, provocando a elevação da pena mínima dentro do intervalo legal, com motivação a ser necessariamente guiada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Na estrutura delineada pelo legislador, somente são utilizados para a fixação da pena-base elementos pertencentes a seus vetores genéricos que não tenham sido previstos, de maneira específica, para utilização nas etapas posteriores. Trata-se da aplicação do princípio da especialidade, que impede a ocorrência de bis in idem, intolerável na ordem constitucional brasileira. 4. O tratamento legal conferido ao tráfico de drogas traz, no entanto, peculiaridades a serem observadas nas condenações respectivas; a natureza desse crime de perigo abstrato, que tutela o bem jurídico saúde pública, fez com que o legislador elegeisse dois elementos específicos necessariamente presentes no quadro jurídico-probatório que cerca aquela prática delituosa, a saber, a natureza e a quantidade

das drogas para utilização obrigatória na primeira fase da dosimetria. 5. Não há margem, na redação do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, para utilização de suposta discricionariedade judicial que redunde na transferência da análise desses elementos para etapas posteriores, já que erigidos ao status de circunstâncias judiciais preponderantes, sem natureza residual. 6. O tráfico privilegiado é instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual. 7. A utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis in idem, expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712). 8. A utilização supletiva desses elementos para afastamento do tráfico privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa. 9. Na modulação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, podem ser utilizadas circunstâncias judiciais não preponderantes, previstas no art. 59 do Código Penal, desde que não utilizadas de maneira expressa na fixação da pena-base. 10. Recurso provido para restabelecimento da sentença". (REsp 1887511/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 01/07/2021) (Sublinhado meu).

Com relação ao regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, anote-se que o delito de tráfico é equiparado aos crimes hediondos, de acordo com a atual redação do artigo 2º, § 1º, da Lei 8.072/90 e, por isso, não se mostra razoável a incidência do regime aberto ou semiaberto para o cumprimento da reprimenda, em que pese não seja obrigatório o regime mais gravoso, devido ao C. Supremo Tribunal Federal – STF ter reconhecido, em caráter incidental, a inconstitucionalidade do parágrafo citado (HC 111.840/ES, Rel. Min. Dias Toffoli).

Porém, convém lembrar, na esteira do julgado citado da Suprema Corte, que isso não invalida a discricionariedade judicial, com possibilidade na análise do caso concreto, de fixação do regime fechado quando entendido como sendo o mais adequado.

No caso dos autos, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado, considerando as circunstâncias judiciais mencionadas, como a grande quantidade e diversidade de entorpecentes, forte no artigo 33, § 3º, do Código Penal.

Ademais, em se tratando de tráfico de drogas, distinto da figura privilegiada, estabelecer regime inicial diverso do fechado acabaria por ofender todo o arcabouço legal relativo à prevenção e reprovação do tráfico de drogas, já que a Constituição Federal, nossa lei maior, em seu artigo 5º, incisos XLIII e LI, estabelece que a lei deverá dispensar tratamento mais gravoso ao crime em questão, autorizando até mesmo a extradição de brasileiro naturalizado, de forma a harmonizar a legislação pátria aos tratados internacionais, relacionados ao combate à traficância, dos quais o país é signatário, não havendo razão para que, neste caso concreto, não dê cumprimento as essas políticas-criminas assumidas.

Por fim, fixo o dia-multa no piso legal, 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, atualizado até o momento do seu efetivo pagamento, por serem parcas as informações acerca da situação financeira do acusado, forte nos artigos 43, da Lei 11.343/06, e 49, § 2º, do Código Penal.

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para, desclassificando a conduta do artigo 12, da Lei 10.826/03, nos termos do artigo 383, do Código de Processo Penal, condenar ENZO FERNANDES INÁCIO, qualificado nos autos, por violação

ao tipo penal previsto no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343/06, a uma pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado; bem como ao pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, diária mínima.

Não há espaço para medidas despenalizadoras.

Nego o apelo em liberdade. Com efeito, na data de hoje, os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva que até então sustentavam a prisão preventiva desse implicado se transformaram em certeza, por meio de cognição exauriente.

Além disso, a pena relativamente alta imposta a esse acusado e o estabelecimento de regime inicial mais severo de cumprimento de pena aplicado na sentença traduzem risco concreto de fuga real, em caso de sua soltura nesta quadra processual.

Assim, visando assegurar a aplicação da lei penal, recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Sobre o assunto, confira-se o entendimento do E. TJSP:

"Tráfico de Drogas - Preliminar - Apelo em liberdade - Impossibilidade - Requisitos do artigo 312 do CPP preenchidos - Preliminar rejeitada - Recurso não provido. Tráfico de Drogas - (...) - Recursos providos em parte. (TJSP; Apelação Criminal 0000864-07.2017.8.26.0628; Relator (a): Klaus Marouelli Arroyo; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Vargem Grande Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 14/10/2020; Data de Registro: 14/10/2020) (Sublinhado meu).

Por outro lado, havendo recurso, expeça-se a guia de execução provisória, conforme o caso.

Custas pelo vencido.

A propósito:

"APELAÇÃO - Tráfico de drogas - Sentença condenatória - (...) Impossibilidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita, não caracterizada no caso em comento, uma vez que os apelantes possuem advogados constituídos nos autos - RECURSOS DEFENSIVOS NÃO PROVIDOS. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO". (TJSP; Apelação Criminal 1502659-13.2021.8.26.0408; Relator (a): Fátima Gomes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ourinhos - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/03/2022; Data de Registro: 31/03/2022) (Ênfase minha).

Caso ainda não se tenha feito, em cumprimento às decisões anteriores, encaminhem-se as drogas apreendidas, bem como os demais apetrechos, oficiando-se à autoridade policial para proceder a sua destruição.

Considerando que as munições apreendidas foram usadas e descartadas para confecção do laudo pericial, nada a apreciar com relação a elas. Já, com relação à arma de fogo, apreendida na mesma oportunidade, determino a remessa ao Exército para as finalidades cabíveis, nos termos do que dispõe o artigo 25, da Lei 10.826/03.

Com relação ao celular apreendido, nada fora produzido nos autos indicando o emprego desse aparelho no crime destes autos, ou mesmo de que era produto do mesmo e de qualquer outro delito. Assim, intime-se a quem de direito, que deverá apresentar prova idônea de sua propriedade, para retirá-lo. Não sendo tal aparelho reclamado, no prazo referido no artigo 123, do Código de Processo Penal, deverá ser vendido em leilão, depositando-se o saldo à disposição do juízo de ausentes, salvo se não apresentar mais conteúdo econômico. Nesse caso, após a devida certificação nos autos, fica autorizada sua destruição, observadas as disposições normativas

pertinentes.

Oportunamente, também após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as seguintes providências: a) Expeça-se o complemento da guia de execução; b) Intime-se o acusado para pagamento da taxa judiciária, nos termos do artigo 479, § 1º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça; c) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, conforme disposto no artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral, c/c artigo 15, inciso III, da Constituição da República; d) Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais para as anotações necessárias; e) Oficie-se a autoridade policial nos termos do artigo 72, da Lei 11.434/06, sobre a amostra guardada para contraprova; e f) Adotadas as cautelas legais, arquivem-se.

P.I.C

Lorena, 06 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA